

乙은 전기·전자제품의 제조업자인 甲과의 사이에 甲이 제조한 물품을 공급받기로 하는 총판대리점 계약을 체결하였는데, 乙은 甲에게 물품대금을 지급함에 있어 그 중 일부는 현금으로 지급하고 그 나머지는 6개월 후에 만기가 도래하는 약속어음을 발행한 후 만기에 은행어음계좌에 그 대금을 입금하는 방식으로 결제하여 왔다.

<제 1 - 1문>

甲은 乙로부터 물품대금 지급과 관련하여 발행·교부받은 액면금 5천만 원의 약속어음에 관한 지급이 거절되자 乙을 상대로 위 어음금 5천만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 법원은 이에 대하여 5천만 원의 물품대금채권의 부존재를 이유로 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고 이는 그대로 확정되었다. 그런데 그 후 甲은 乙을 상대로 위 물품대금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 이에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (30점)

甲 → 乙
어음
청구기각.

판결이!

기각

증거판단

... 청구기각!

1. 기판력

2. 어음판단

3. 신빙성? 증명책임

<추가된 사실관계>

乙의 총판대리점은 사업부진으로 인하여 2015. 9.30. 甲으로부터의 물품 수령을 마지막으로 문을 닫게 되었는데, 甲은 乙에게 마지막으로 물품을 공급한 당일 그 대금 지급과 관련하여 乙로부터 만기가 2016.3.30.로 된 액면금 3억원의 약속어음을 발행·교부받은 다음 만기가 도래하기 전 丙에게 위 어음을 배서양도 하였고 丙이 만기가 도래한 후 乙에게 위 어음을 지급제시 하였으나 그 지급이 거절되자 丙은 乙을 상대로 위 어음금 3억원의 지급을 구하는 소송을 제기하면서 그 증거방법으로 乙이 발행한 위 어음을 제출하였다.

<제 1 - 2문>

위 어음에 대한 증거조사절차에서 乙은 위 어음상의 인영은 자신의 인장에 의한 것임이 분명(인영부분 인정)하지만, 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인(위조항변)하였고 丙은 이에 대하여 다투었다. 법원이 심리한 결과, 乙이 주장한 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우와 乙의 주장사실(위조사실)이 진실인 것으로 밝혀진 각각의 경우에 있어서 법원은 어음의 형식적 증거력에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (20점)

甲 → 乙
↓
丙
제시.
아무런 증거도 없음

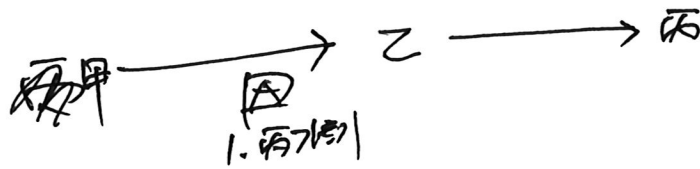
이단위추정

인영 → 인인

관제
진정성립

i) 이단위 추정. 형식적 증거력 0

ii) 부증 → 추정불가능. " X



乙은 2012.1.28. 丙으로부터 돈을 빌리면서 이를 담보하기 위하여 자신이 살고 있는 A건물에 대하여 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기를 丙 명의로 경료해 주었다. 그런데 甲이 A건물은 자신의 토지 위에 무단으로 건축된 것이라고 주장하면서 乙을 상대로 토지 소유권에 기한 방해배제청구로서 2015.5.1. 그 지상물인 A건물의 철거 및 토지인도청구 소송을 제기하였다.

<제 2문>

법원은 甲이 乙을 상대로 제기한 위 소송에서 甲의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 2016.1.6. 그대로 확정되었는데, 乙은 그 후인 2016.1.25. A건물에 관하여 위 가등기에 기한 본등기를 丙 명의로 경료하여 주었다. 甲은 乙에 대한 승소확정판결을 가지고 A건물을 철거할 수 있는가? (20점)

甲은 乙이 운전하던 택시를 타고 가던 중, 그 택시가 그 앞에 진행하던 자동차와 충돌하는 바람에 중상을 입고 병원에 입원하여 치료를 받고 있던 중, 乙을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다.

<제 3 - 1문>

甲은 위 소송에서 乙이 앞차를 보고 제동을 하였으나 과속으로 달린 탓으로 택시가 정차하지 않고 밀리면서 앞차를 들이 받았다고 주장하였고, 乙은 과속한 사실이 없다고 주장하였다. 법원은 甲과 乙 사이에 쟁점이 된 과속여부에 대하여는 판단하지 않은 채, 乙이 전방주시의무를 태만히 하다가 뒤늦게 제동하는 바람에 사고가 발생한 것이므로 乙에게 손해배상책임이 있다고 판단하였다. 법원의 위 판단은 적법한 것인가? (20점)

甲 → 乙

주관 vs 객관

<제 3 - 2문>

위 소송 계속 중 甲은 위 교통사고로 인하여 뇌손상에 의한 거동불능의 상태가 되었다. 이에 원고 측은 이 부분에 대하여 청구취지를 확장하였고, 신체감정결과 기대여명이 10년일 것으로 인정되어 제1심 법원은 기왕치료비와 일실수익 및 위자료와는 별도로 향후 10년간 매월 100만원씩의 치료비를 지급하라는 판결을 선고하였고, 그 판결은 그대로 확정되었다. 그런데 그로부터 2년이 지난 후 甲이 예상과는 달리 건강이 크게 호전된 경우 乙은 어떠한 소송상의 조치를 취할 수 있는가? (10점)

정정

<제1-1문>

1. 문제의 소재 (2점)

원인채권의 부존재를 이유로 어음금청구를 기각한 판결이 확정된 후, 원인채권의 지급을 구하는 소가 제기된 경우, 후소법원은 전소법원의 판단에 구속되는가, 즉 전소판결의 기판력이 후소에 미치는가?

2. 기판력의 발생여부 (13점)

(1) 원인채권(물품대금채권) 청구소송과 어음금채권청구소송의 소송물의 이동(異同)

소송물이론 중 구소송물이론(판례)은 양 채권의 실체법상의 권리가 다르기 때문에, 신소송물이론 중 이지설은 사실관계가 다르기 때문에 별개의 소송물이라고 보지만, 이지설은 청구취지가 동일하다는 이유로 동일한 소송물로 파악함.

(2) 사안에의 적용

판례(대법원 1965.11.30.선고 65다2028 판결) 및 이지설에 의하면 위 양 소송은 그 소송물을 각기 달리하는 것이다. 따라서 전소에서의 물품대금채권의 부존재라는 판단은 선결적 법률관계에 관한 판결이유 중의 판단으로서 기판력이 발생되지 않는다. 즉 물품대금채권의 존부는 후소와의 관계에서 선결적 관계가 되는 전소의 소송물이 아니기 때문에 전소판결의 기판력은 후소에 미치지 아니한다.

3. 전소판결의 후소에 대한 구속력 여부 (15점)

(1) 문제점

전소에서의 소송물의 존부를 판단함에 있어 전제가 되는 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 기판력이 발생하지 않는다는 원칙을 그대로 관철할 경우 전소에서와 후소에서 서로 모순저촉되는 판결이 나올 수 있기 때문에 그 방지를 위한 이론들이 전개되어 있다.

(2) 전소에서의 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 일정한 구속력을 인정할 필요가 있다는 견지에서 일본의 쟁점효이론, 의미관련론, 경제적가치동일성론, 신의칙설(선행행위와 모순되는 거동금지) 등이 대두되어 있다.

(3) 판례의 입장

확정된 민사, 형사판결에서 인정된 사실은 유력한 증거가 되므로 합리적 이유의 설시 없이(즉 특별한 사정이 없는 이상) 배척할 수 없고, 특히 두 개의 민사소송의 당사자가 같고 분쟁의 기초사실이 같은 경우에는 전소의 판단이 후소에 유력한 증거자료로서의 효력,

즉 증명효가 생긴다. <대법원 2006.6.24.선고 2008다92312 판결>

- (4) 판례의 증명효 이론에 따르면 법원은 특별한 사정이 없는 이상 물품대금채권의 부존재 사실을 인정하여 갑의 청구를 배척(기각)하여야 할 것이다.

<제1-2문 >

1. 어음(사문서)의 형식적 증거력(진정성립)의 의의 (3점)

2. 사문서가 증거로 제출된 경우 거증자가 그 성립의 진정을 증명하여야 하지만(민소법 357조) 그 문서에 본인 또는 대리인의 서명 · 날인 · 무인이 그의 진정한 의사에 기한 것임을 증명한 때에는 진정한 문서로서 추정을 받는다(민소법 358조). (2점)

3. 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우에 있어서 어음의 형식적 증거력 (8점)

문서에의 서명 · 날인사실이 증명된 것은 아니지만 작성명의인의 인영이 그 사람의 도장에 의하여 현출된 것이라는 사실이 인정되면(인영부분 인정) 그 날인행위가 그 사람의 의사에 기하여 행해 진 것이라고 사실상 추정되고, 일단 날인행위의 진정이 추정되면 그 문서 전체의 진정성립이 추정된다(이른바 2단계 추정). 따라서 사례에 있어 어음의 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우, 즉 을이 인장의 도용 사실이나 강박에 의한 날인사실 등에 관한 증명을 하지 못한 이상, 법원은 2단계 추정에 따라 어음의 형식적 증거력을 인정하여야 한다.

4. 을의 주장사실이 진실한 것으로 밝혀진 경우에 있어서 어음의 형식적 증거력 (7점)

문서상의 날인이 그 작성명의인의 인영임이 틀림없으나 그 작성명의인(을)이 아닌 제3자가 날인한 것으로 밝혀진 경우에는 진정성립의 추정이 깨진다. 따라서 거증자인 정이 제3자에게 위 약속어음의 작성에 관한 권한이 있었음을 증명하지 못하는 이상 법원은 어음의 형식적 증거력을 인정하여서는 안 된다.

<제2문>

1. 기관력의 주관적 범위에 관한 문제로 병이 변론종결 후의 승계인에 해당하는지의 여부가 문제이다.

변론종결 후 소송물인 권리관계 자체를 승계한 자는 아니나, 계쟁물에 관한 당사자적격을 이전받은 자도 승계인에 포함된다고 보는 것이 일반적이다. (3점)

2. 다만, 소송물이론 중 구이론(판례)은 원고의 청구가 대세효가 있는 물권적 청구권에 기한 것인 경우(사례의 경우가 이에 해당한다)와 대인적 효력밖에 없는 채권적 청구권에 기한 것인 경우를 구분하여, 전자의 경우에 있어서 변론종결 후 계쟁물을 양수한 자(계쟁물에 관한 당사자적격을 취득한 자)는 민소법 218조 제1항 소정의 승계인에 해당되어 기판력이 미치지만, 후자의 경우에 있어서 계쟁물을 양수한 자는 위 승계인에 해당되지 않아 기판력이 미치지 않는 것으로 본다. 반면 신이론은 원고의 청구를 위와 같이 구분하지 않고서 변론종결 후 계쟁물을 양수한 자를 모두 위 승계인에 해당되는 것으로 본다. (7점)
3. 병이 기판력을 받기 위해서는 승계의 시기가 변론종결 후일 것을 요하는데, 통설과 판례는 사안과 같이 가등기는 변론종결 전, 이에 기한 본등기는 변론종결 후에 경료된 경우에 있어서 판례는 본등기 경료시를 기준으로 하여 병을 변론종결 후의 승계인으로 보고 있다.<대법원 1992.1.27. 선고 92다10883 판결> (5점)
4. 병은 변론종결 후의 승계인으로서 갑은 을에 대한 승소판결문에 기하여 승계집행문을 부여 받아 병 소유 건물인 A건물을 철거할 수 있다. (5점)

<제3-1문>

1. 변론주의의 의미 (3점)
2. 주장책임이란? (5점)
3. 과속한 사실과 전방주시의무를 태만히 한 사실은 각 주요사실인가, 간접사실인가? 대립하고 있는 학설의 입장을 간단히 설시하고 나름대로의 결론도출 (12점)

<제3-2문>

1. 정기금판결에 대한 변경의 소란 ? (5점)
2. 요건 (민소법 252조의 내용을 기재하면 족함) 및 결론도출 (5점)